Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 12ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810303

Processo nº 0130540-70.2021.8.17.2001

AUTOR: ERIVALDO COSTA BANDEIRA

REU: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SENTENÇA

Vistos, etc ...

ERIVALDO COSTA BANDEIRA, devidamente qualificada na peça vestibular, por intermédio de advogado legalmente constituído, maneja ***AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA*** contra UNAFISCO SAÚDE/SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, igualmente identificado nos autos, sob os argumentos expendidos a seguir.

Pugnou, inicialmente, pela concessão da gratuidade da justiça, sob o argumento de não poder arcar com o adimplemento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família. Em sua peça inaugural, alegou ser segurada do plano de saúde contratado junto à demandada, com a qual firmou contrato de prestação de serviços médico-hospitalares. Ainda, que é portador de FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (FPI) (CID J84.1), cujo diagnóstico foi determinado em 2019 após início dos sintomas respiratórios, os quais levaram a procura de diagnóstico e tratamento clínico. Afirmou, inclusive, que seu médico assistente lhe prescreveu o tratamento medicamentoso intitulado NINTEDANIBE (OFEV) por tempo indeterminado, a fim de reduzir a progressão da doença e aumentar a sobrevida do paciente. Argumentou que, desde o ano de 2014, o aludido medicamento foi aprovado pela *Food and Drug Administration* (FDA) para o tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática nos EUA e, em janeiro de 2015, pela *European Medicines Agency* (EMA). Além disso, que a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia também recomenda a utilização do **NINTEDANIBE (OFEV)** para os pacientes com Fibrose Pulmonar Idiopática que exibam maiores chances de benefício com o tratamento". Garantiu que a ANVISA concedeu registro sanitário (nº 1.0367.0173) para o medicamento OFEV (esilato de nintedanibe) cápsula mole 100 mg e 150 mg em 26 de outubro de 2015 para a empresa Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda. Positivou também que apesar de ter solicitado, administrativamente (Protocolo nº 36101120212230241327), em 5/11/2021, a liberação do custeio do tratamento medicamentoso pela operadora de saúde Amil, recebeu como resposta a notícia de não cobertura do tratamento perseguido. Asseverou que, em fevereiro de 2021, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) incluiu o medicamento OFEV (Esilato de Nintedanibe) no Rol de Procedimentos para tratamento oncológico. Por fim, em sede de tutela de urgência, requereu que a demandada fosse compelida a fornecer o medicamento mensalmente, na dose indicada pelo médico pneumologista (150mg 2 vezes ao dia) (doc. 09 e doc. 10), sob pena de multa diária. No mérito, pelejou pela confirmação da tutela de urgência. Atribuiu à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Carreou documentos.

Determinou-se a emenda da inicial (id. 94738428 – págs. ½), no sentido de corrigir o valor atribuído à causa. Ainda, houve concessão de prazo ao autor para comprovar sua hipossuficiência.

O demandante atravessou petição (id. 96029607 – págs. 1/34) por intermédio da qual reiterou o pleito de gratuidade da justiça; requereu prioridade na tramitação do processo, por ser idoso; repetiu os argumentos acerca da necessidade de fornecimento do fármaco, juntando farta jurisprudência a respeito e atribuiu à causa o valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

Custas adimplidas (id. 96493467 – pág. 1).

Deferiu-se a tutela de urgência (id. 96691410 – págs. 1/3).

Restou malograda a tentativa de conciliação (id. 100831556 – pág. 1).

Devidamente citada, a demandada atravessou Contestação (id. 102464616) por intermédio da qual suscitou, como **preliminar**, impugnação ao valor da causa, devendo atingir a monta de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), porquanto ser mais razoável e proporcional. No mérito, argumentou que *"a Requerida se trata de organização sindical representativa da categoria profissional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil – AFRFB e atua no mercado da saúde suplementar na condição de operadora de planos de saúde que presta assistência médica na forma de AUTOGESTÃO, sem fins lucrativos, e sob sistema mutualista"*, razão pela qual não seria aplicável o Código de Defesa do Consumidor (ex vi súmula n. 608 do STJ). Argumentou que o tratamento com o medicamento em questão, não está previsto nas Diretrizes de Utilização do Rol de Procedimentos Médicos editado pelo ANS, razão pela qual sua conduta deve ser reconhecida como lícita.

Houve apresentação de Réplica (id. 105430175).
Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

Antes de analisarmos o mérito da causa, faz-se necessário o enfrentamento da **preliminar**.

A demandada suscitou, como preliminar de contestação, a impugnação ao valor atribuído à causa.

De plano, rechaço referenciada preliminar, haja vista que, em consonância com o disposto no §2º, do art. 292, do CPC, o laudo médico prescreveu o fármaco de modo a ser ingerido duas vezes ao dia, por tempo indeterminado, atraindo, portanto, o aludido dispositivo, que orienta no sentido de que para o caso de cobrança de prestação continuada e de prazo indeterminado, deve a causa corresponder à prestação anual. Desse modo, mantenho incólume o despacho que determinou a emenda à inicial a fim de alterar o valor da causa.

Passemos à análise do **mérito**.

De início é de se frisar que em função de emergir suficiente a documentação constante dos autos à formação de convicção, tem-se como despicienda a produção de outros meios de prova, circunstância que, a teor do disposto no artigo 355, inciso I, do Estatuto de Ritos, autoriza o julgamento antecipado da lide.

Da não incidência do Código de Defesa do Consumidor nos planos de saúde na modalidade de autogestão:

Pacificou-se na jurisprudência do entendimento segundo o qual não se aplica o CDC aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão.

Eis o teor do verbete sumular nº 608, do STJ:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - PLANO DE SAÚDE - MODALIDADE DE AUTOGESTÃO - NÃO INCIDÊNCIA DO CDC - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. **A Segunda Seção desta Corte Superior consagrou o entendimento de não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, haja vista a inexistência de relação de consumo** (Súmula nº 608/STJ). 2. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp: 1696327 SP 2017/0237136-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 23/08/2018, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 03/09/2018).

Todavia, em que pese não se aplique o CDC ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, isso não significa que devem ser vulnerados os princípios da boa-fé e função social do contrato, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. GEAP. CDC. INAPLICABILIDADE. CANCELAMENTO DO PLANO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ABUSIVIDADE. 1. **A inaplicabilidade do CDC aos planos de saúde na modalidade de autogestão não implica em inobservância aos princípios da boa-fé e da função social do contrato** (arts. 421 e 422 do CC). O art. 423 do CC determina que, no contrato de adesão, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente. 2. O cancelamento do contrato de seguro sem a notificação prévia do segurado e sua eventual ciência e autorização revela-se abusivo, em afronta aos artigos 13, II da Lei n. 9.656/98. Dever de restabelecimento do contrato. Precedentes. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078409943, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/09/2018).

Significa dizer que, mesmo não se tratando de relação de consumo, o Código Civil prevê a necessidade de proteção do vulnerável contratual, com a vedação da onerosidade excessiva e de cláusulas antissociais por abuso de direito (art. 187).

Vale dizer, é de ser ressaltado que o contrato não dispensa a boa-fé entre as partes contratantes, como está estatuído no artigo 422 do Código Civil vigente:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Pois bem após profunda análise fático-jurídica, depreende-se caber razão aos pleitos autorais.

Analisando o presente caso à luz do recentíssimo julgamento, em 8 de junho de 2022, do EREsp nº 1886929/SP do STJ acerca da taxatividade do rol da ANS, percebe-se que o autor pretende o tratamento mediante fornecimento de fármaco que objetivamente consta como classificado pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na classe terapêutica de antineoplásico, conforme aferível em seu sítio na rede mundial de computadores (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351456304201563/ (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351456304201563/)).

Observe-se, inclusive, o que dispõe a Anvisa, em seu Parecer Público (id. 94705487 – págs. 1/7), a respeito:

"A fibrose pulmonar idiopática (FPI) é uma forma específica da pneumonia intersticial fibrosante progressiva, crônica sem causa conhecida. A FPI ocorre principalmente em adultos idosos e é limitada aos pulmões e está associada ao padrão histopatológico e/ou radiológico da pneumonia intersticial usual (PIU). Apesar de a FPI ser a mais comum das 7 pneumonias intersticiais idiopáticas, ela ainda é uma doença rara, e , fatal, com um tempo médio de sobrevida de 2 a 3 anos após o diagnóstico. O fator de crescimento derivado de plaquetas (FCDP) está envolvido no desenvolvimento da fibrose pulmonar. O FCDP é um potente mitógeno para fibroblastos e parece desempenhar um papel essencial na expansão dos miofibroblastos pela estimulação da proliferação, migração e sobrevida.

O único medicamento atualmente registrado em diversos países para o tratamento da FPI é pirfenidona, aprovada no Japão, Coréia do Sul, Índia, China e Argentina para o tratamento da FPI e na UE e Canadá para o tratamento da FPI de leve a moderada. Outras opções farmacológicas incluem corticosteroides, azatioprina, ciclofosfamida e N-acetilcisteína, embora nenhum deles recebe a indicação para o tratamento da FPI.

*Dessa forma, o **desenvolvimento da nintedanibe, se justifica pela necessidade de melhor tratamento em pacientes com Fibrose Pulmonar Idiopática, tendo em vista que os tratamentos atuais são limitados**."*

Com relação às indicações terapêuticas, assim dispõe aludido órgão regulatório:

"Ofev (esilato de nintedanibe) cápsula mole está indicado para o tratamento e retardo da progressão da fibrose pulmonar idiopática (FPI)".

No tocante ao mecanismo de ação, assim se manifestou a ANVISA:

"Nintedanibe liga-se competitivamente ao sítio de ligação de ATP desses receptores e bloqueia a sinalização intracelular, que é crucial para a proliferação, migração e transformação de fibroblastos, representando mecanismos essenciais para a fisiopatologia da FPI".

Outrossim, em suas considerações finais, alegou que *"A Anvisa avaliou que os dados de eficácia e segurança disponíveis demonstraram que **o Ofev (nintedanibe) ofereceu benefício significativo aos pacientes com fibrose pulmonar idiopática. Para comprovar a eficácia e segurança do medicamento, foram realizados uma série de estudos não clínicos e clínicos do medicamento e esses estudos demonstraram que os benefícios do medicamento superam o risco**"*.

Por fim, afirmou que *"concedeu **registro sanitário** (nº 1.0367.0173) para o medicamento **Ofev (esilato de nintedanibe)** cápsula mole 100 mg e 150 mg em 26 de outubro de 2015 para a empresa Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda"*.

Sendo assim, a procedência é medida que se impõe.

Logo, considerando que o tratamento perseguido está autorizado pela ANS, o processo deve ser extinto, com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC, devendo ser acolhido o pleito formulado na inicial.

Registre-se, por oportuno, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe ao profissional da saúde indicar o tratamento a ser experimentado pela paciente, e não ao plano de saúde. Vale dizer, o médico e não o plano de saúde é responsável pela orientação terapêutica e que entender de modo diverso põe em risco a vida do consumidor.

Na verdade, se não fosse assim, estar-se-ia autorizando que a empresa se substituísse aos médicos na escolha da terapia adequada de acordo com o plano de cobertura do paciente. Somente o médico detém a atribuição de avaliar e escolher a melhor alternativa de tratamento, que melhor convém à cura do paciente. Entender de modo diverso põe em risco a vida do consumidor.

Acresça-se, ainda, o posicionamento do mesmo Tribunal Superior ao considerar abusiva a clausula limitativa que impede o paciente de receber tratamento com o método mais moderno disponível no momento em que instalada a doença coberta.

Com escopo de ilustrar o argumentado alhures, faz-se pertinente explicitar a decisão abaixo:

Seguro saúde. Cobertura. Câncer de pulmão. Tratamento com quimioterapia. Cláusula abusiva. 1. O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura. Se a patologia está coberta, no caso, o câncer, é inviável vedar a quimioterapia pelo simples fato de ser esta uma das alternativas possíveis para a cura da doença. A abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, em razão de cláusula limitativa, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno disponível no momento em que instalada a doença coberta. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 668216 / SP – RECURSO ESPECIAL 2004/0099909-0 - DJ 02/04/2007 - p. 265)

No mesmo sentido: STJ – AgInt no AREsp 1900466 RJ 2021/0171897-5, Rel. Min. Moura Ribeiro, pub. 1/12/2021; STJ – REsp 1971313 SP 2021/0348230-0, Rel. Min. Moura Ribeiro, pub. 1/12/2021; STJ – AREsp 1947632 RO 2021/0229665-4, Rel. Min. Humberto Martins, pub. 30/09/2021.

Emerge flagrante a fragilidade material da peça defensiva, vez que, da detida ponderação dos elementos de prova carreados e dos argumentos arregimentados, restou caracterizada situação prejudicial à parte demandante suscetível de intervenção judicial supletiva.

Consabido é que o espírito do Código Civil, tal qual é o Código de Defesa do Consumidor, é tutelar o hipossuficiente, tratando desigualmente os desiguais à medida em que evidencia os princípios da boa-fé (art. 421, do CC/02), da função social do contrato (art. 422, do CC/02) e da interpretação mais favorável ao aderente (art. 423, do CC/02), assegurando-lhe, quando plausível o dano material ou moral, o direito à indenização. A incidência destas normas ao negócio jurídico que fundamenta o pleito é indiscutível.

Preocupado com a livre formação da vontade do contratante, o legislador estabeleceu no aludido Diploma regras de proteção contra cláusulas abusivas, sancionando-as de nulidade absoluta com o intuito de resguardar o equilíbrio entre os contratantes.

É o que dispõe o art. 424, do CC/02:

"Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio".

Para tanto, foi atenuado o princípio da força obrigatória do contrato, permitindo-se, inclusive, modificação das cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais e a revisão das prestações excessivamente onerosas, observada sempre a interpretação mais favorável ao contratante.

Analisando a causa à luz destes princípios, aflora palpável a ausência de plausibilidade jurídica das alegações tecidas pela ré.

No caso concreto, é notório que a parte demandada, ao promover a negativa de cobertura do procedimento requestado, sob o argumento de que o tratamento não consta no rol de coberturas obrigatórias da ANS, incorreu em pratica abusiva, devendo-se, nesse caso, reconhecer a nulidade das cláusulas limitadoras de cobertura, em estrita obediência ao Código Civil Brasileiro, senão observemos:

Ora, nesses casos, deve-se reconhecer a nulidade das cláusulas limitadoras de cobertura, em obediência aos princípios supraepigrafados, senão vejamos:

Súmula nº 35, TJPE: *"A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde pode dar ensejo à indenização por dano moral".*

Ora, a conduta da demandada se mostra, de fato, abusiva. Não me parece razoável que se exclua determinada opção de tratamento se o demandante está assistido por médico assistente. O contrato dispõe sobre as patologias cobertas, não sobre o tipo de tratamento para cada patologia alcançada pela avença. Na verdade, se não fosse assim, estar-se-ia autorizando que a empresa se substituísse aos médicos na escolha da terapia adequada de acordo com o plano de cobertura do paciente.

A seguradora não poderia se valer de cláusula notoriamente desfavorável ao segurado para furtar-se da responsabilidade pela cobertura do procedimento encetado. Panorama no qual é lícito concluir que, da forma como elaboradas, as cláusulas delimitadoras de garantia e de cobertura de exames e procedimentos são nulas por gerarem considerável desequilíbrio contratual, capaz de expor o consumidor à situação prejudicial.

É possível, portanto, verificar a fragilidade dos argumentos tecidos em contestação, vez que a própria ANS, em relatório (id. 94705487 – págs. 1/7), reconheceu a eficácia do fármaco perseguido.

Dessa forma, há que se reconhecer como abusiva a conduta da requerida em o negar o tratamento à autora.

Posto isto, com arrimo nos fundamentos fáticos e jurídicos ora explicitados, resolvo, com espeque no art. 487, I, do CPC, JULGAR PROCEDENTE a pretensão entabulada na peça vestibular, para, neste comando sentencial, tornar definitiva a tutela de urgência concedida *initio litis*.

Condeno a demandada a pagar custas processuais e taxa judiciária com base no valor atribuído à causa, e a pagar honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa (obrigação de fazer) devidamente atualizado.

P.I. Observadas as cautelas legais.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido após o prazo de 15(quinze) dias, remeta-se os autos ao arquivo com anotações de estilo, sem prejuízo de eventual posterior ingresso de cumprimento de sentença.

Recife, 10 de agosto de 2022.

Marcus Vinícius Nonato Rabelo Torres

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: MARCUS VINICIUS NONATO RABELO TORRES
10/08/2022 10:36:06
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 112006488

22081010360606400000109516919

IMPRIMIR GERAR PDF